

RECURSO CÍVEL Nº 5068699-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CESAR DO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ADICIONAL NOTURNO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PLEITO DO AUTOR PARA APLICAÇÃO DO FATOR 150 EM SUBSTITUIÇÃO AO FATOR 200 E PARA QUE O PERÍODO DO TRABALHO NOTURNO (22H AS 5H) SEJA COMPUTADO COMO 8 HORAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, mantendo integralmente a sentença, sob seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5068699-46.2024.4.02.5101

510015608972 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5068699-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CESAR DO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União em face da sentença proferida pelo Juiz *a quo* (evento 28), que julgou procedente o pleito autoral, a fim de condenar a parte ré ao pagamento das quantias a título de adicional noturno (art. 75 Lei nº 8.112/90), cujos valores serão apurados com base no divisor de 150 horas mensais, computando 8 (oito) horas ao período laborado entre as 22 h. de um dia e as 05 h. do dia seguinte, enquanto submetida à jornada de 30 horas semanais de trabalho, bem como ao pagamento das diferenças decorrentes do período em que a parcela foi paga sob o divisor 240h e 200h, respeitada a prescrição quinquenal e descontadas as eventuais parcelas já pagas a este título.

Em suas razões recursais (evento 32), a União alega que a relação jurídica havida entre a parte autora e a UFRJ tem natureza jurídica estatutária, não sendo possível aplicar à essa relação jurídica dispositivos próprios do regime celetista. Assim, informa: *“O regime estatutário é caracterizado pelo princípio da legalidade estrita, inexistindo relação contratual entre o servidor o ente público. Já o regime celetista possui natureza nitidamente contratual, havendo margem para negociação individual e coletiva. No Direito do Trabalho, o conflito de normas é resolvido pelo critério da norma mais favorável, o que é inaplicável ao Direito Administrativo, dada a sua submissão ao princípio da legalidade.”*

Menciona que, de acordo com as fichas financeiras anexadas aos autos, resta comprovado o pagamento do serviço extraordinário à parte autora, em alguns meses, realizado dentro dos limites legais. Diz que, embora o autor esteja submetido a uma jornada de 40 horas semanais, o seu trabalho é realizado em regime de “escala de revezamento”.

Com isso, diz que o trabalho do autor em horário noturno não pode ser considerado como período de serviço extraordinário, não fazendo jus o autor ao recebimento do adicional, salvo em situações excepcionais e temporárias, mediante autorização expressa, nos termos da legislação supracitada.

Alega a União: “nota-se que o argumento referente a “25ª hora” não cumpre os requisitos da temporariedade e excepcionalidade. Com isso não se quer adentrar na questão da suficiência, ou não, de mão de obra no setor. O que se está a afirmar é que, caso acatado o argumento, estar-se-ia instituindo o pagamento de uma hora extra com habitualidade, visto que o Agente Penitenciário federal faria jus ao pagamento dessa hora em todo plantão que realizasse. A própria expressão “25ª hora” é contrária às noções de temporariedade e excepcionalidade exigidas pela Lei 8.112, de 1990, e pela Orientação Normativa SEGEP nº. 03, de 2015.”

Diz que: “o sistema remuneratório dos servidores públicos deve ser previsto em lei (cf. art. 37, X, da Constituição Federal), de modo que não cabe a esta Consultoria Jurídica, por meio de parecer, aumentar permanentemente a remuneração dos Agentes Penitenciários federais, sob o argumento de eventual repercussão da hora ficta noturna na duração da jornada de trabalho dos servidores plantonistas.”

Afirma que: “o próprio regime de plantão, nos termos em que previsto no parágrafo único do art. 143 da Lei nº. 11.907, de 2009, torna inviável o reconhecimento da “25ª hora”. Aliado ao regime de plantão, deve-se somar a natureza das atividades desenvolvidas pela parte autora, que devem ser contínuas e sem lacunas no serviço. É seguro afirmar, portanto, que deve ser afastado aquilo que, estando previsto no regime ordinário da jornada de trabalho do servidor público, seja incompatível com as peculiaridades da prestação do serviço no regime de plantão.”

Alega que: “[...] a jornada de trabalho em regime de plantão é fixada considerando uma dimensão de ônus e outra de bônus. Isso porque, em que pese a necessidade de o servidor exercer continuamente suas atividades por longo período, após esse período, ele poderá usufruir de descanso muito superior, ou seja, mais do que é concedido aos servidores que trabalham em jornada normal.”

Menciona que: “O adicional vem sendo corretamente pago pela Universidade, que tem aplicado o percentual previsto em Lei (25%) sobre a hora trabalhada pelo servidor. O cálculo da hora trabalhada, por sua vez, leva em consideração a jornada de trabalho a que o cargo do servidor está submetido, qual seja, 40 horas semanais, como comprovado no documento em anexo.”

Por fim, diz que: “o cálculo do adicional noturno, no caso em comento, terá como base o fator de 240 horas mensais, e não as 150 horas pretendidas pela autora, considerando a jornada de trabalho prevista em lei para o cargo da autora, que é de 08 horas diárias, multiplicado por 30 dias (mês civil).”

Contrarrazões do autor no evento 36, em que menciona: “É evidente que a análise da parte Ré está totalmente equivocada e fere todos os fundamentos e princípios da matemática, visto que, a carga horária máxima semanal é de 30 horas, em regime de plantão com escala de 30 x 150 horas, além de complementações.”

Dito isso, requer o autor a manutenção da r. sentença, bem como a condenação da União em honorários advocatícios.

É o relatório. Decido.

VOTO

Foi proferida sentença pela Juíza de 1ª. Instância, nos seguintes termos:

“[...]”

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a ré ao pagamento das quantias a título de adicional noturno (art. 75 Lei nº 8.112/90), cujos valores serão apurados com base no divisor de 150 horas mensais, computando 8 (oito) horas ao período laborado entre as 22h00 de um dia e as 05h00 do dia seguinte, enquanto submetida à jornada de 30 horas semanais de trabalho, bem como ao pagamento das diferenças decorrentes do período em que a parcela foi paga sob o divisor 240h e 200h, respeitada a prescrição quinquenal e descontadas as eventuais parcelas já pagas a este título.

Os valores pretéritos deverão ser apurados no cumprimento de sentença, devendo incidir o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 na redação dada pela Lei 11.960/09, no que se refere a juros e correção monetária, de modo que seja aplicada a TR (índice da caderneta de poupança) até 25/03/2015, passando, a partir de então, a correção monetária a correr pelo IPCA-E (conforme a modulação dos efeitos da ADIn 4.357/DF) e os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97). A partir de 09/12/2021, em substituição aos índices anteriores, será aplicado exclusivamente sobre o débito até então apurado, uma única vez, a SELIC, consoante disposto na EC nº 113/2021, artigo 3º.

Fica, desde logo, autorizada a compensação com eventuais valores pagos na via administrativa sob idêntico título.

a constatação da procedência da pretensão da parte autora não implica homologação de eventuais quantias trazidas nos autos, sendo que a parte ré poderá demonstrar eventual excesso em fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas ou em honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

[...]"

Inicialmente, esclareço que o autor não exerce o cargo de agente penitenciário, nem exerce suas atribuições na UFRJ, conforme constou no recurso inominado da União.

O autor é servidor público federal, o qual está vinculado ao Ministério da Saúde, exercendo o cargo de enfermeiro no Hospital Federal dos Servidores do Estado (evento 01 - FINANCS).

Esclarecida tal questão, verifico que a controvérsia reside na interpretação que a Administração Pública confere ao artigo 19 da Lei 8.112/090 para fins de consideração do total de horas mensais trabalhadas e seu reflexo no cálculo da hora-extra, *in verbis*:

Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)

O autor diz que exerce suas atribuições em regime de plantão, com escala de 30 x 150 horas, mas que o entendimento do Ministério da Saúde é de que o divisor correto seria o fator 200, e não o fator 150.

A pretensão do autor é no sentido de que o cálculo seja efetuado pelas efetivas horas semanais trabalhadas (divisão de 30 horas semanais por 6 dias úteis) multiplicadas por 30 dias.

O autor é servidor público federal, cujo vínculo jurídico é regido pela Lei 8.112/90, o qual realiza a carga horária semanal de 30 horas, em regime de plantão.

No presente caso, a sentença de origem verificou a correta aplicação do divisor 150 h., por meio de divisor que é alcançado por meio de uma simples operação aritmética. Divide-se o número máximo de horas semanais trabalhadas (30 h.) pela quantidade de dias úteis de uma semana (6, considerando sempre o sábado como dia útil) e multiplicando-se o resultado pelo total de dias de cada mês (30).

A jurisprudência pátria reconhece o direito ao Adicional Noturno calculado conforme a jornada semanal efetiva do servidor público, inclusive permitindo a aplicação do divisor 150 h. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. DIVISORES. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão que negou provimento à remessa necessária e à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o IFES ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional noturno, "aplicando-se o fator de divisão 200 (duzentos) para o cálculo do adicional noturno devido aos servidores que laborem 40 (quarenta) horas semanais; o fator de divisão 150 (cento e cinquenta) para os que trabalhem 30 (trinta) horas semanais; e o fator de divisão 100 (cem) para os que trabalhem 20 (vinte) horas semanais, devendo ser considerado como base de cálculo o vencimento básico e as gratificações permanentes estabelecidas em lei". In casu, pugna a embargante pelo prequestionamento explícito dos seguintes temas: adequação do divisor, devendo ser considerado na contagem o descanso semanal remunerado; o caráter transitório do adicional noturno, ou seja, após as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte, não faz jus ao recebimento da vantagem; exclusão dos docentes do rol de eventuais beneficiários, pois exercem suas funções em regime de dedicação exclusiva, o que afastaria o direito ao adicional noturno, nos termos do art. 21 da Lei 12.772/2012. Não há que prosperar a irresignação da embargante, pois, na hipótese, o julgado se posicionou no sentido de que os servidores do IFES fazem jus ao adicional noturno, com o divisor 200 (duzentos), devido aos servidores que laborem 40 (quarenta) horas semanais; o fator de divisão 150 (cento e cinquenta) para os que trabalhem 30 (trinta) horas semanais; e o fator de divisão 100 (cem) para os que trabalhem 20 (vinte) horas semanais, devendo ser considerado como base de cálculo o vencimento básico e as gratificações permanentes estabelecidas em lei. Desta forma, verifica-se que os trabalhadores que laboram 40 (quarenta) horas semanais, ou seja, em regime de dedicação exclusiva, fazem jus ao adicional noturno, não havendo omissão em relação a tal fato. Válido destacar que mesmo para efeitos de prequestionamento, os embargos de declaração só poderão ser acolhidos, se presentes qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se constata na situação vertente. É cediço que eventual discordância acerca do posicionamento do órgão judicante não se apresenta como motivo hábil a ensejar a interposição deste recurso, ficando este restrito às hipóteses expressamente previstas na lei. Nítido se mostra que os embargos de declaração não se constituem como via recursal adequada para suscitar a revisão na análise fático-jurídica decidida no acórdão. Frise-se, por oportuno, que em se tratando de embargos de declaração opostos para rediscutir tese já afastada e inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a advertência de que eventual reiteração de cunho protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do §3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Embargos declaratórios

improvidos.

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2 , Apelação/Remessa Necessária, 5010580-14.2018.4.02.5001, Rel. MARCELO DA FONSECA GUERREIRO , Assessoria de Recursos , Rel. do Acórdão - MARCELO DA FONSECA GUERREIRO, julgado em 02/02/2022, DJe 21/02/2022 21:12:29) (Grifo nosso)

Como se observa, plenamente possível a aplicação do fator 150 no cálculo do Adicional Noturno devido ao demandante, porquanto provado que cumpre jornada semanal de 30h.

Pontue-se, por relevante, que não há ofensa ao teor do enunciado lavrado pela Turma Nacional de Uniformização - TNU no Tema nº 69, porquanto seu conteúdo diz respeito aos servidores submetidos à jornada de 40h semanais:

"O fator de divisão para o cálculo do serviço extraordinário é de 200 horas mensais, em razão da jornada máxima do servidor público de 40 (quarenta) horas semanais prevista no art. 19 da Lei n. 8.112/90".

Registre-se, *mutatis mutandi*, precedente desta 6ª Turma Recursal, por unanimidade, conforme processo nº 5038478-80.2024.4.02.5101 da relatoria da Dra. KARLA Nanci Grandó, na sessão extraordinária de 02/10/2024, bem como no processo 5013189-31.2023.4.02.5118, de relatoria da Dra. ALESSANDRA BELFORT BUENO, com julgamento na sessão extraordinária de 31/07/2024.

Assim, à luz da jurisprudência pátria e com fulcro na fundamentação supra, o cálculo do adicional deve observar o divisor de 150 horas, mantida a jornada semanal de 30h a que está sujeita o demandante.

Ressalto, ainda, que cada hora do período noturno (22 h. às 05 h. do dia seguinte) equivale a 52 minutos e 30 segundos para efeito de pagamento do adicional noturno, nos termos do artigo 75 da Lei nº 8.112/90.

Assim, 07 (sete) horas trabalhadas no período noturno devem ser consideradas como o período de 08 (oito) horas.

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida.

Ante todo o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso da parte ré, mantendo integralmente a sentença, sob seus próprios fundamentos. Condene a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.